공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2026 - 085호 2026. 5. 4.

사 건 번 호 2024하조0906

사 건 명 대방건설(주)의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피 심 인 대방건설 주식회사
고양시 일산동구 중앙로 1072(백석동, 아이비프라자 5층)
대표이사 구○○
대리인 법무법인(유) 율촌
담당변호사 박○○, 강○○, 김○○, 주○○

심의종결일 2026. 3. 30.

주 문

1. 피심인은 수급사업자에게 건설공사 등의 전부 또는 일부를 위탁하면서 준공검사가 완료되기 전임에도 수급사업자가 하자보수보증금을 예치하거나 하자보수보증증권을 교부할 때까지 기성금 지급을 거절 또는 보류할 수 있다는 내용의 계약조건을 설정하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 수급사업자에게 건설공사 등의 전부 또는 일부를 위탁하면서 계약 체결 시 책정된 폐기물 처리비를 초과하여 발생한 비용을 그 발생 원인이나 책임 소재와 관계 없이 수급사업자에게 전적으로 부담시키는 내용의 계약조건을 설정하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 145,000,000원

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인은 건설산업기본법 제2조 제7호의 규정에 따른 토목건축공사업 등을 영위하는 중소기업자가 아닌 자[1]로서, 이 사건과 관련하여 주식회사[2] 대성건설, 미강건업 등 205개 수급사업자들에게 건설 또는 제조를 위탁하였으므로, 「하도급거래 공정화에 관한 법률[3]」 제2조 제2항 제1호의 규정에 의한 원사업자에 해당한다.

나. 피심인 및 수급사업자 일반현황

2 이 사건 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

(이하 표 삽입을 위한 여백)

---

1) 피심인은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공시대상기업집단인 '대방건설'에 소속된 사업자이므로 중소기업자가 아닌 사업자이다.

2) 이하 회사명 기재에 있어서는 '주식회사' 기재는 생략하거나 ㈜로 기재한다.

3) 2025. 4. 1. 법률 제20893호로 개정되기 전의 것을 말하고, 이하 '법'이라 한다.

<표 1> 피심인 일반현황

(단위: 십억 원)

상호	매출액			자산총액			시공능력평가액		
	'21년	'22년	'23년	'21년	'22년	'23년	'21년	'22년	'23년
대방건설(주)	1,471	1,184	856	1,957	2,173	2,495	3,248	3,928	3,947

* 심사보고서 소갑 제1호증[4] 및 전자공시시스템(DART) 자료

3 이 사건 수급사업자들의 일반현황은 <별지 1>과 같다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 하자담보 유보금 부당특약 설정행위

1) 인정사실

가) 하자담보 유보금 특약 설정 및 삭제 경위

4 피심인은 2021. 4. 1.부터 2022. 3. 14.까지[5] 총 ***개 수급사업자와 체결 또는 이행된 총 ***건의 하도급계약에서, "최종 총 계약금액의 10%에 해당하는 금원을 원사업자에게 예치하거나, 수급사업자가 하자보수보증증권을 원사업자에게 제출할 때까지 수급사업자에게 최종 총 계약금액의 10%에 해당하는 금원의 지급을 거절하거나 보류할 수 있다"는 내용의 약정(이하 '이 사건 유보금 특약'이라 한다)을 계약서 본문이나 특수조건에 설정하였다. 이 사건 유보금 특약이 설정된 하도급계약 현황은 <별지 2>와 같다.

(이하 표 삽입을 위한 여백)

4) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

5) 피심인은 2021. 4. 1. 이전부터 해당 특약을 운용해 왔으나, 법상 조사개시대상 기준 등을 고려하여 2021. 4. 1. 현재 유효하거나 해당일 이후 체결된 하도급 거래로 한정하였다.

<표 2> 건설공사 하도급계약서 내용 발췌

13.기 타 사 항

가. 수급인이 최종 총 계약금액의 10%에 해당하는 금원을 보증금액으로 하고 제10항의 하자담보책임기간을 보증기간으로 하는 하도급계약 일반조건 제22조 제1항 각 호의 보증서를 도급인에게 제출할 때까지 도급인은 수급인에 대한 잔여 기성금 또는 정산금 중 최종 총 계약금액의 10%에 해당하는 금원의 지급을 거절하거나 보류할 수 있다.

* 소갑 제5호증

<표 3> 건설공사 하도급계약 특수조건 발췌

제9조 (최종정산 승인절차)

③ 원사업자는 수급사업자가 최종 총계약금액의 10%에 해당하는 금원을 하자보수보증금으로 원사업자에게 예치하거나 위 금원을 보증금액으로, 계약상 하자담보책임기간을 보증기간으로 하는 하자보수보증증권을 원사업자에게 제출할 때까지 수급사업자에 대한 잔여 기성금 또는 정산금 중 최종 총 계약금액의 10%에 해당하는 금원의 지급을 거절하거나 보류할 수 있다.

* 소갑 제5호증

5 다만, 피심인은 동 문구가 법 위반에 해당할 가능성이 높다는 내부 검토에 따라, 2022. 3. 15.부터 계약서에서 해당 문구를 삭제하였다.

6 피심인 법무팀은 2021. 12. 9. '기성금 하자보수예치금 보유불가 관련 보고의 건'이라는 제목하에 '기성대금에서 해당 금액(공사 대금의 10%)를 하자보수보증금 명목으로 예치하고 지급하지 아니하였으며, 이는 하도급법 제13조 제1항에 위반될 가능성이 매우 높다고 판단'된다고 대표이사에게 보고하였다.

<표 4> 기성금 하자보수예치금 보유불가 관련 보고(2021.12.13.) 발췌

보고 경위	하수급인은 당사와 체결한 하도급계약의 내용에 따라 하자보수보증금을 당사에 현금으로 납부하거나 하자보수보증증권을 발급하여 제출하여야 함. 그러나, 하수급인이 하자보수보증금 납부 또는 하자보수보증증권을 발급받지 아니한 경우가 발생하여 당사는 기성대금에서 해당 금액(공사대금의 10%)를 하자보수보증금 명목으로 예치하고 지급하지 아니하였음. 이후 하자담보책임기간이 경과하면 해당 금액을 하수급인에게 다시 지급하지만 그리하더라도 하도급법 제13조 제1항에 위반될 가능성이 매우 높다고 판단됨. 이에, 관련 판례를 첨부하여 하도급법 위반가능성에 대해 보고드리고자 함.

* 소갑 제7호증

7 이후 2022. 3. 14. 피심인은 재차 내부 검토를 거쳐 법상 부당특약(제3조의4) 및 하도급대금 지급의무 위반(제13조) 등에 해당될 소지가 있음을 이유로 하자담보 유보금에 해당하는 '총 계약금액의 10%에 해당하는 금원의 지급을 거절하거나 보류할 수 있다'는 문구를 삭제하기로 결정하였다.

<표 5> 피심인 계약서 내 부당특약 문구 삭제 및 수정 보고 (2022.3.14.) 발췌

1. 보고내용

가. 당사의 하도급 거래 관련한 법무법인 율촌의 법률자문 용역 결과 당사가 사용하는 계약서 중 일부 항목에서 부당특약 등 문제 소지가 발견 됨.

나. 이에, 법무법인 율촌의 의견과 당사 법무팀 의견을 종합하여, 당사 전자계약서 내용 중 하도급거래 공정화에 관한 법률 및 공정거래위원회 부당특약 심사지침에 반하는 내용을 수정 하고자 함.

■ 하도급 관련 법률자문 당사 계약 부당특약 요약 보고 :

구분	당사 계약 내용
1	하도급 계약서(갑지) 제13항 제가호. ~~"...보증서를 도급인에게 제출할 때까지 도급인은 수급인에 대한 잔여기성금 또는 정산금 중 최종 총 계약금액에 10%에 해당하는 금원의 지급을 거절하거나 보류할 수 있다."(삭제)~~

위반사항
하자보수보증금 또는 하자보수보증서를 납부받도록 규정하는 것 자체는 이상없음. 하도급법 제13조는 하도급대금의 지급거절이나 그 지연을 인정한다는 예외규정을 두지 않음.

* 소갑 제8호증

나) 구체적 적용 사례

8 피심인은 이 사건 유보금 특약에 따라 최종 총 계약금액의 10%에 해당하는 금원의 지급을 일정한 방식으로 거절하거나 보류하였다.[6] 이하에서는 이 사건 유보금

6) 하자담보 유보금 설정과 관련하여, 피심인 소속 이○○ 차장은 ▲매 기성금에서 10%만큼을 유보하는 방식(기성별 분할 유보 방식)과, ▲마지막 기성 때 계약금액의 10%를 유보하는 방식(최종기성 일괄 유보 방식)으로 구분되고, 이는 처음 공사 시작 시 수급사업자와 협의하여 정한다고 답변하였다. 다만, '기성별 분할 유보 방식'으로 유보금을 설정한 사례는 본 건 조사 과정에서 확인된 바는 없고, 6면 이하에서 살펴볼 4개사 사례는 '최종기성 일괄 유보 방식'으로 판단된다.

<표> 피심인 소속 이○○ 차장 진술조서(2024.4.4.) 중 발췌

문) **하자담보 명목의 유보는 어떤 방식으로 이루어집니까.** 매월 수급사업자가 100만큼 기성청구하면, 그에 대해 10을 유보하여 90만큼 지급하는 방식입니까

답) 아닙니다. 전체 계약금액이 1억이면 천만원을 유보하는데, **1억을 5번에 걸쳐 2천씩 기성한다고 가정할 때 처음부터 200씩을 유보하도록 할 건지 아니면 2천씩 기성하고 마지막에는 천만원만 기성하고 유보된 천만원은 하자보증이행증권발행 후 받도록 할 것인지 선택하도록 합니다. 이걸 처음 공사 시작할 때 하도급업체와 협의 후에 진행**합니다.

* 소갑 제6호증

특약에 따라 실제 하자담보 유보금 조항이 적용된 사례(이하 '이 사건 적용 사례'라 한다)를 살펴본다.

(1) ○○○○ 사례

9 피심인은 ○○○○을 대상으로 ○○○○○○○○○○○○○○ 신축공사 중 조적·미장·견출공사[7] 관련 하도급계약을 ****. **. **. 체결하였다.[8]

10 피심인은 동 계약을 체결하면서 계약금액의 10%를 기성 유보율로 설정하였다. 이는 "수급인이 하자담보 보증서를 제출할 때까지 잔여 기성금 또는 정산금 중 최종 총 계약금액의 10%에 해당하는 금원의 지급을 거절하거나 보류할 수 있다"는 계약서상 내용을 그대로 따른 것이다.

<표 6> 대성건설과의 건설공사 하도급계약서 발췌

13.기 타 사 항
가. 수급인이 최종 총 계약금액의 10%에 해당하는 금원을 보증금액으로 하고 제10항의 하자담보책임기간을 보증기간으로 하는 하도급계약 일반조건 제22조 제1항 각 호의 보증서를 도급인에게 제출할 때까지 도급인은 수급인에 대한 잔여 기성금 또는 정산금 중 최종 총 계약금액의 10%에 해당하는 금원의 지급을 거절하거나 보류할 수 있다.

* 소갑 제14호증

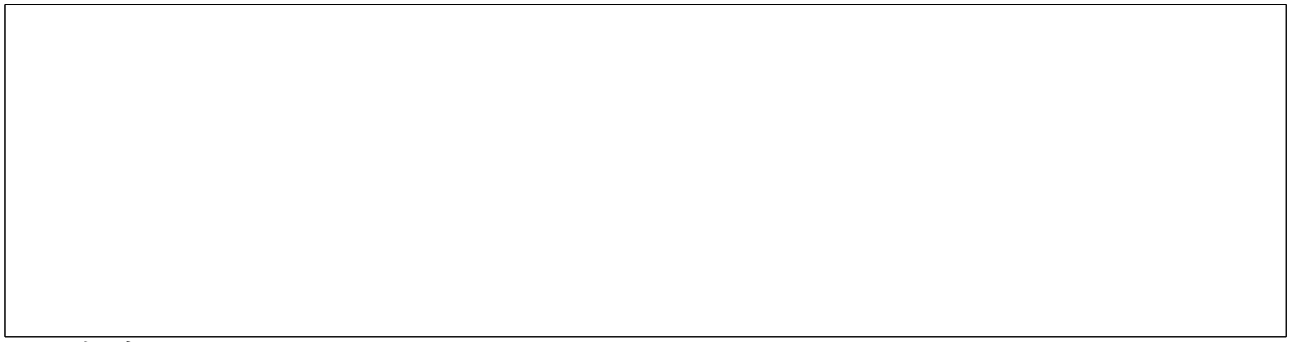
11 한편, ○○○○은 계약서상 준공일인 ****. *. **. 보다 8개월 이상 이른 시점인 ****. *. **. 피심인에게 '기성유보금으로 인하여 지속적으로 경비, 노무, 재료비가 선투입되어 재무상황에 어려움이 지속적으로 발생하고 있다'는 이유로, '기성유보율을 10%에서 5%로 변경'해달라는 요청을 하였다.

---

7) 조적·미장·견출 공사는 건축 마감 공사의 한 부분으로, 벽돌이나 블록 등의 조적 구조물을 쌓은 후 표면을 정리하고 마감하는 작업이다. 조적공사는 벽돌, 블록 등을 사용하여 구조체를 쌓는 작업이며, 미장공사는 조적된 벽의 표면을 매끄럽게 정리하는 작업이다. 견출공사는 미장된 표면을 더욱 정밀하게 다듬는 과정이다.

8) 동 계약서상 공사계약 기간은 ****. **. **.(착공일)부터 ****. *. **.(준공일)까지이다. 동 계약에서 조적·미장·견출공사는 기본형과 확장형으로 나누어 진행되었다. 이에 따라 피심인은 ○○○○과 조적·미장·견출공사와 관련하여 총 2개의 계약을 체결하였다(소갑 제14호증 참고). 해당 계약들은 동시에 체결되었으며, 유보금 관련 내용도 동일하게 포함되므로 이를 일괄하여 설명한다.

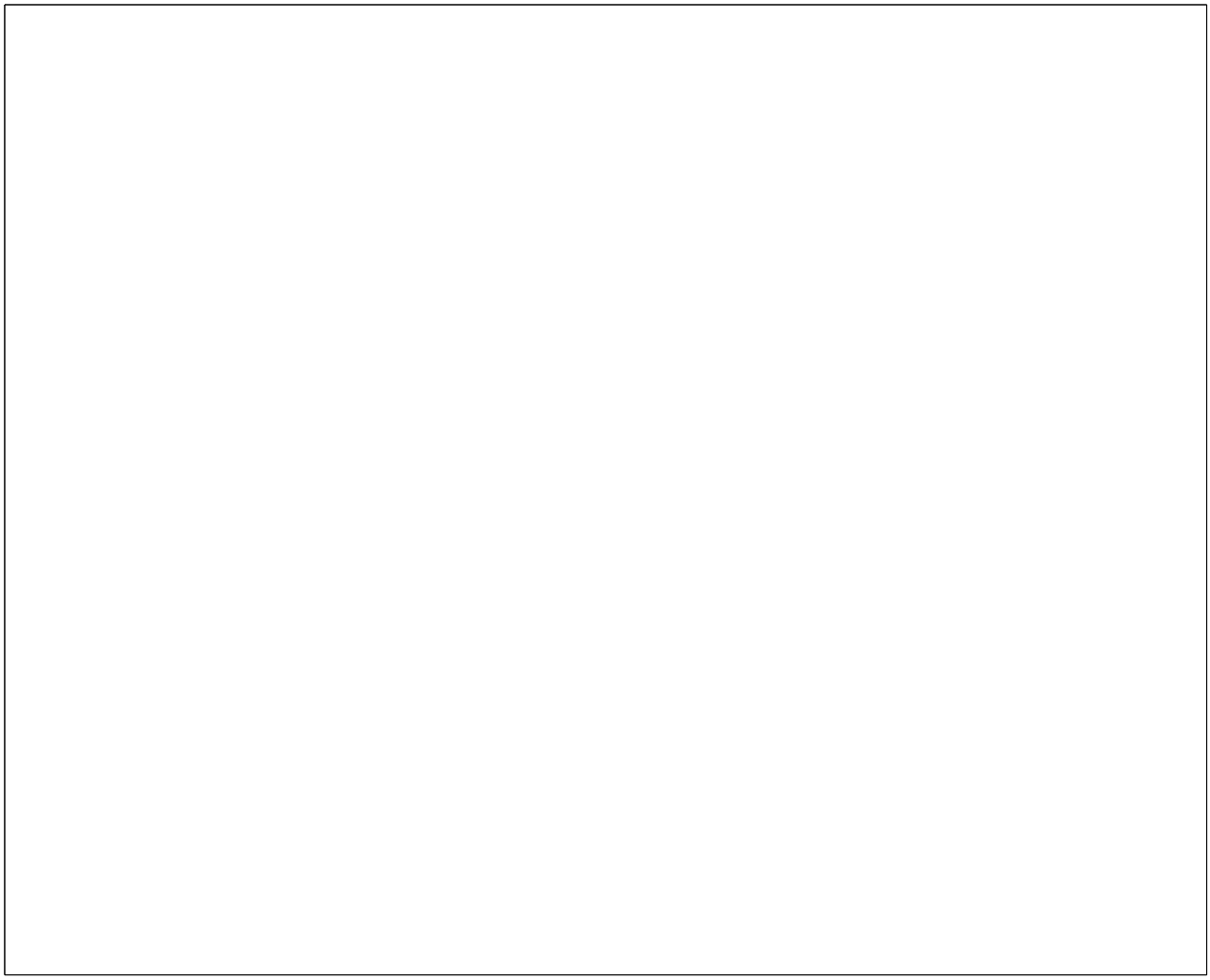
<표 7> ○○○○의 기성유보율 변경 요청 공문 발췌



* 소갑 제15호증

12 피심인은 이러한 요청에 대해 내부 검토 및 결재를 거쳐 ****. *. *. 기성유보율을 10%에서 5%로 인하하였다.

<표 8> 대성건설의 기성유보율 변경 요청 관련 피심인 내부 결재 문건 발췌



* 소갑 제16호증

(2) ○○○○ 사례

13 피심인은 ○○○○○○○○○○○○○○ 신축공사 중 골조공사[9] 관련 하도급계약을 ○○○○과 ****. *. *. 체결하였다.[10]

14 피심인은 계약을 체결하면서 ○○○○에게도 계약금액의 10%를 기성 유보율로 설정하였다. 이는 “최종 총계약금액의 10%에 해당하는 금원을 하자보수보증금으로 원사업자에게 예치하거나, 하자보수보증증권을 원사업자에게 제출할때까지 수급사업자에 대한 잔여 기성금 또는 정산금 중 최종 총 계약금액의 10%에 해당하는 금원의 지급을 거절하거나 보류할수 있다”고 명시한 하도급계약 특수조건에 따른 것이다.

<표 9> ○○○○과의 건설공사 하도급계약서 내 하도급계약 특수조건 발췌

제9조 (최종정산 승인절차)

③ 원사업자는 수급사업자가 최종 총계약금액의 10%에 해당하는 금원을 하자보수보증금으로 원사업자에게 예치하거나 위 금원을 보증금액으로, 계약상 하자담보책임기간을 보증기간으로 하는 하자보수보증증권을 원사업자에게 제출할 때까지 수급사업자에 대한 잔여 기성금 또는 정산금 중 최종 총 계약금액의 10%에 해당하는 금원의 지급을 거절하거나 보류할 수 있다.

* 소갑 제18호증

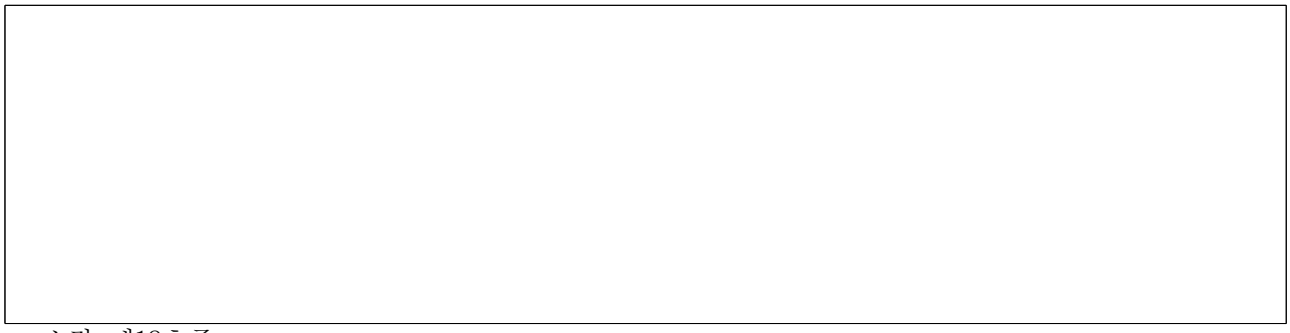
15 한편, ○○○○은 피심인에게 ****. *. *. ‘기성금 유보율 변경 요청의 건’ 공문을 보내며, 피심인으로부터 수령한 기성대금이 ○○○○의 기 지출 및 예정지출 기성대금에 비해 부족하여 하도급 기성집행에 어려움이 예상되므로 ‘기성금 유보율을 10%에서 5%로 변경’해 줄 것을 요청하였다.

---

9) 골조공사는 건축물의 기본 구조를 형성하는 공사로, 형틀(거푸집)공사, 철근공사, 콘크리트 공사, 비계공사 등을 포함한다. 형틀공사는 콘크리트를 원하는 형태로 만들기 위해 틀을 제작하는 공사, 철근공사는 콘크리트의 인장강도를 보강하기 위해 철근을 배치하는 공사, 콘크리트 공사는 철근을 보강한 거푸집에 콘크리트를 타설하여 구조체를 형성하는 공사, 비계공사는 작업자의 안전과 시공의 편의성을 위해 임시구조물(발판, 가설구조물)을 설치하는 공사이다.

10) 동 계약상 공사계약 기간은 ****. *. **.(착공일)부터 ****. *. **.(준공일)까지이다. 동 계약에서 골조공사는 형틀, 철근, 콘크리트 비계 공사로 구성되며, 1공구와 2공구로 나누어 진행되었다. 이에 따라 피심인은 ○○○○과 골조공사와 관련하여 총 6개의 계약을 체결하였다(소갑 제18호증 참고). 해당 계약들은 동시에 체결되었으며, 유보금 관련 내용도 동일하게 포함되므로 이를 일괄하여 설명한다.

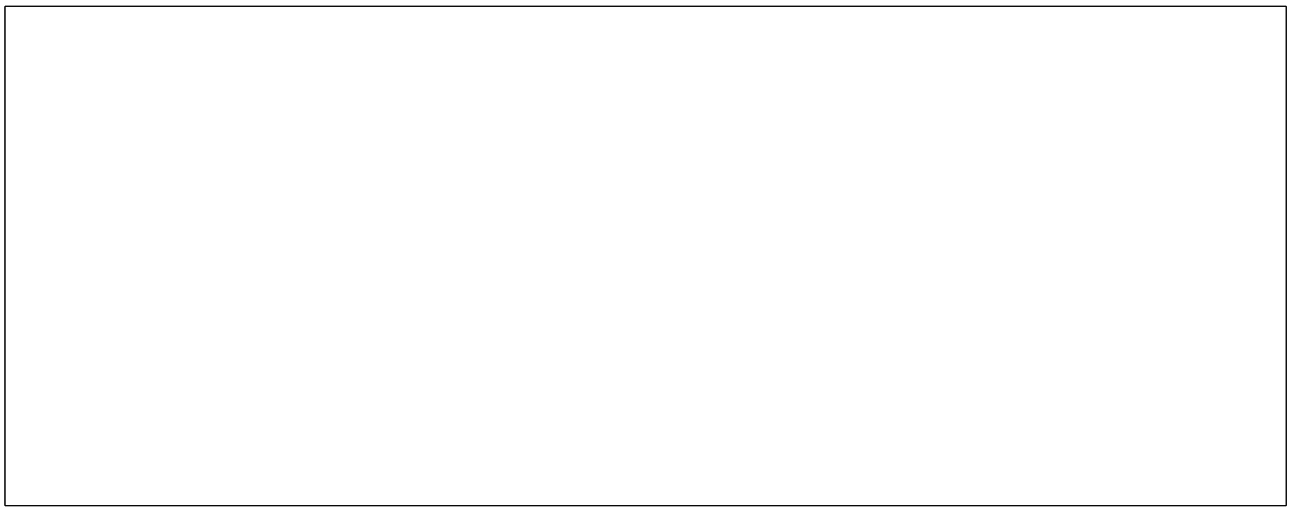
<표 10> ○○○○의 기성유보율 변경 요청 공문 발췌



* 소갑 제19호증

16 피심인은 ****. *. **. 위 요청에 대해 향후 ○○○○이 수령할 수 있는 기성금액으로는 노무, 자재, 장비 등의 투입비용을 집행하기 어렵다는 점, 즉 ○○○○의 자금운영의 어려움 호소를 감안하여, 기성유보율을 10%에서 5%로 인하하기로 결정하였다.

<표 11> ○○○○의 기성유보율 변경 요청 관련 피심인 내부 결재 문건 발췌



* 소갑 제20호증

17 기성유보율 인하 이후에도 피심인은 2021. 9. 29.부터 2022. 11. 29.까지 총 9번의 기성금을 추가로 ○○○○에 지급하였고, 유보금은 기성유보율이 인하된지 1년 2개월 이상 지난 2022. 11. 29. 지급되었다.[11)]

11) 해당 유보금은 ○○○○이 하자보수보증증권을 피심인에 제출하면서 지급되었다.

(3) ○○○○ 사례

18 피심인은 ○○○○을 대상으로 ○○○○○○○○○○○○○○○ 신축공사 중 조적·미장·견출공사 관련하여 ****. *. *. 하도급계약을 체결하였고,[12] ○○○○에게도 계약금액의 10%를 기성 유보율로 설정하였다.

19 ○○○○은 최종 기성금이 지급되기 4개월 전인 ****. *. **. '기성 유보율을 10%에서 5%로 변경'해줄 것을 요청하는 공문을 피심인에게 보냈다.

20 동 공문에서 ○○○○은 '자재값 인상 및 공사 지연으로 인하여 예상하지 못한 투입비가 많이 발생되어 당초 기성금 유보율을 적용하면, 원가 부담이 가중되고, 인건비 및 자재, 장비대의 결제일이 늦어지면 작업자 및 장비 이탈로 이어져 이중 고통을 겪게 된다'는 취지를 요청 근거로 기재하였다.

<표 12> ○○○○의 기성금 유보율 변경 요청 공문 발췌

* 소갑 제23호증

21 피심인은 내부검토를 거쳐 ****. *. **. 기성유보율을 5% 인하하기로 결정하였으며, 이후 2021. 6. 28.부터 10. 29.까지 총 4번 더 ○○○○에 기성금을 지급하였다. 유보금은 마지막 기성 지급일인 2021. 10. 29. 지급되었다.[13]

12) 동 계약서상 공사계약 기간은 ****. *. **.(착공일)부터 ****. *. **.(준공일)까지이다.
13) 해당 유보금은 ○○○○이 하자보수보증증권을 피심인에 제출하면서 지급되었다.

(4) ○○○○ 사례

22 피심인은 ○○○○을 대상으로 ○○○○○○○○○○○○○○ 신축공사 중 조적·미장·견출 공사 관련 하도급계약을 ****. *. *. 체결하였고,[14] ○○○○에게도 계약금액의 10%를 기성 유보율로 설정하였다.[15]

23 ○○○○은 계약서상 준공일보다 약 4개월 전인 ****. *. **. 경[16] 피심인에게 '잔여공사를 진행함에 있어 지속적인 노임 및 장비대가 발생하고 있을 뿐만 아니라 기 발생한 미결제 자재대 등으로 인해 현장 운영 및 자재 수급에 영향을 끼칠 수 있다'는 이유로 기성유보율을 10%에서 5%로 변경해줄 것을 요청하는 공문을 보냈다.

<표 13> ○○○○의 기성금 유보율 변경 요청 공문 발췌

4) 당초 기성 유보율 : 10% → 변경 요청 기성 유보율 : 5% 5) 사유 : 아파트 세대 땜빵 및 잔여 공사를 진행함에 있어 지속적인 노임 및 장비대가 발생하고 있을 뿐만 아니라 기 발생한 미결제 자재대 등으로 인해 현장 운영 및 자재 수급에 영향을 끼칠 수 있다고 판단되어 부득이하게 당초 기성금 유보율(10%)이 아닌 계약금액 대비 기성 유보율(5%) 변경을 요청드리오니

* 소갑 제28호증

24 피심인은 내부검토를 거쳐 ****. *. **. 기성유보율을 5% 인하하기로 결정하였으며, 이후 2021. 6. 28.부터 2021. 11. 29.까지 추가로 총 4차례의 기성금을 미래앤현에 지급하였다. 특히 유보금은 2021. 11. 29. 지급되었다.[17]

2) 근거

14) 동 계약서상 공사계약 기간은 ****. *. *.(착공일)부터 ****. *. **.(준공일)까지이다.

15) 동 계약에서 조적·미장·견출공사는 기본형과 확장형으로 나누어 진행되었다. 이에 따라 피심인은 ○○○○과 조적·미장·견출공사와 관련하여 총 2개의 계약을 체결하였다(소갑 제26호증 참고). 해당 계약들은 동시에 체결되었으며, 유보금 관련 내용도 동일하게 포함되므로 이를 일괄하여 설명한다.

16) 피심인 제출자료(2025. 3. 28.)(소갑 제27호증) 중 13. 질의 관련 답변에 따르면 2021. 5. 20.경으로 확인된다.

17) 해당 유보금은 ○○○○이 하자보수보증증권을 피심인에 제출하면서 지급되었다.

25 위와 같은 사실은 피심인 제출자료(2025.2.14.)(소갑 제1호증), 피심인 제출자료(2024. 12. 10.)(소갑 제2호증), 피심인 제출자료(2024. 1. 24.)(소갑 제3호증), 피심인 제출자료(2025. 2. 28.)(소갑 제4호증), 하도급계약서(2022. 3. 15. 이전)(소갑 제5호증), 피심인 공무부 차장 이○○ 진술조서(2024. 4. 4.)(소갑 제6호증), 기성금 하자보수 예치금 보유불가 관련 보고(2021. 12. 13)(소갑 제7호증), 피심인 계약서 내 부당특약 문구 삭제 및 수정 보고(2022. 3. 14.)(소갑 제8호증), 피심인 제출자료(2024. 12. 30.)(소갑 제9호증), 피심인 제출자료(2025. 3. 14.)(소갑 제11호증), ○○○○○○○ 대상 ○○○○○○ 조적·미장·견출공사 하도급계약서(소갑 제14호증), ○○○○○○○의 기성유보율 변경 요청 공문(소갑 제15호증), ○○○○○의 기성유보율 변경 요청 관련 피심인 내부 결재 문건(소갑 제16호증), ○○○○○○○ ○○○○○○ 하도급공사 관리대장 및 기성유보금 지급 내역(소갑 제17호증), ○○○○○○○ 대상 ○○○○○○ 골조공사 하도급계약서 일체(소갑 제18호증), ○○○○○○○의 기성유보율 변경 요청 공문(소갑 제19호증), ○○○○○○○의 기성유보율 변경 요청 관련 피심인 내부 결재 문건(소갑 제20호증), ○○○○○○○ ○○○○○○ 하도급공사 관리대장 및 기성유보금 지급 내역(소갑 제21호증), ○○○○○○○ ○○○○○○ 방수공사 하도급계약서(소갑 제22호증), ○○○○○○○의 기성금 유보율 변경 요청 공문(소갑 제23호증), ○○○○○○○ 및 ○○○○○○○의 기성유보율 변경 요청 관련 피심인 내부 결재 문건(소갑 제24호증), ○○○○○○○ ○○○○○○ 하도급공사 관리대장 및 기성유보금 지급 내역 (소갑 제25호증), ○○○○○○○ ○○○○○○ 조적·미장·견출 하도급계약서(소갑 제26호증), 피심인 제출자료(2025.3.28.)(소갑 제27호증), ○○○○○의 기성금 유보율 변경 요청 공문(소갑 제28호증), ○○○○○○○ ○○○○○○ 하도급공사 관리대장 및 기성유보금 지급 내역(소갑 제29호증), ○○○○○○○ 대상 ○○○○○ 타일공사 계약서 등 관련 내역 일체(소갑 제30호증), ○○○○○○○○○○ 대상 ○○○○○○ 내부석공사 계약서 등 관련 내역 일체 (소갑 제31호증), 계약사례별 내역 정리(소갑 제32호증), 건설 하도급공사 유보금 설정 실태 및 개선방안(소갑 제33호증), 서울고등법원 20누47641판결문(2021.6.2)(소갑 제34호증), 피심인 제출자료(2024.5.3.)(소갑 제35호증), 피심인 제출자료(2025.1.6.)(소갑 제36호증), 피심인 제출자료(2025.1.20.)(소갑 제37호증), 피심인 제출자료(2025.3.21.)(소갑 제38호증), 피심인 수급사업자 현황(소갑 제39호증), 2022년 3월 15일 계약서 변경 전 하도급계약

현황(소갑 제40호증), 심의 과정에서의 전체 진술(PPT 자료 포함) 등을 통해 인정된다.

3) 관련 법령 및 법리

가) 관련 법령

하도급거래 공정화에 관한 법률

제3조의4(부당한 특약의 금지)
① 원사업자는 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건(이하 "부당한 특약"이라 한다)을 설정하여서는 아니 된다.
② (생략)

나) 법리

26 법 제3조의4 제1항에 따라 원사업자는 수급사업자에게 건설공사 등을 위탁하면서 계약서, 약정서 등 그 명칭이나 형태를 불문하고 원사업자와 수급사업자 간의 권리·의무 관계에 영향을 미치는 약정을 통해 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하여서는 아니된다.

27 여기서 '수급사업자의 이익'은 수급사업자가 원사업자와 하도급거래를 함으로 인하여 얻게 되는 이윤발생, 기업성장, 사업확대, 종사원의 소득증대, 기술축적 등 다양한 유무형의 경제적인 혜택을 의미[18]한다.

28 부당특약의 금지규정은 상호 대등한 지위에 있는 거래당사자 사이나 정상적인 거래관행이 작동하는 경우에는 받아들여지기 어려운 요구이더라도 수급사업자가 원사업자와의 계속적인 거래관계를 유지하기 위해 부득이 그 요구에 의하여 약정을 체결할 수밖에 없는 점을 고려하여 원사업자가 자신의 우월적 지위를 이용하여 수급사

18) 「부당특약 심사지침」 Ⅴ. 1. 가. 참조

업자에게 불리한 조항을 계약서에 추가함으로써 피해를 입히는 것을 방지함으로써 부당한 특약을 설정하는 행위 그 자체를 금지하려는 데 그 취지가 있다.[19]

29 이때 부당성의 유무는 하도급거래의 계약조건이 공정하고 타당한지 여부를 기준으로 판단하게 되는데, 계약조건이 원사업자와 수급사업자가 상호 대등한 입장에서 충분한 협의과정을 거쳐 결정하였는지, 당해 특약을 정한 의도와 목적, 특약을 설정하게 된 경위, 수급사업자의 원사업자에 대한 거래의존도, 특약 설정으로 인한 효과와 영향, 당해 업종의 통상적인 거래관행에 어긋나는지, 하도급법 및 건설산업기본법 등 관계 법령의 취지에 부합하는지, 수급사업자가 입은 불이익의 내용과 정도 등을 종합적으로 고려하여 정상적인 거래관행을 벗어난 것으로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지를 판단하여야 한다.[20]

4) 위 2. 가. 1) 행위의 위법 여부

30 피심인의 위 2. 가. 1) 행위는 아래와 같은 점에서, 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건을 설정한 행위에 해당한다.

31 첫째, 본 특약은 준공검사 후 하자보수보증 의무를 규정한 건설업종 표준하도급계약서와 달리 준공검사와 무관하게 유보금 설정의 효력이 발생하도록 규정하여 준공 전 단계의 수급사업자의 대금 수령권을 침해한다.

32 건설업종 표준하도급계약서 제57조 제1항은 “수급사업자는 이 계약에서 정한 하자보수보증금률을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하“하자보수보증금”이라 한다)을 준공검사 후 그 공사대금을 지급 받을 때까지 현금 또는 증서로 원사업자에게 납부 또는 교부한다.”고 규정하여 수급사업자의 하자보수보증 의무는 준공검사 완료 시점에 성립하는 것으로 규정하고 있다.

19) 서울고등법원 2016. 12. 21. 선고 2015누2040, 서울고등법원 2017. 3. 30. 선고 2016누37753 판결, 서울고등법원 2025. 11. 6. 선고 2024누37833 판결 등

20) 서울고등법원 2025. 11. 6. 선고 2024누37833 판결

33 반면, 본 특약은 ‘준공검사 후’라는 명확한 시점을 규정하고 있지 않으며, 정산금뿐만 아니라 ‘잔여 기성금’에 대해서도 지급을 거절할 수 있다고 정하여 준공검사 완료 이전 단계에서도 유보금 설정을 가능하게 함으로써 아직 성립하지도 않은 수급사업자의 의무를 이유로 대금 지급 거절을 가능하게 한다.

34 둘째, 본 특약은 동시이행관계에 따라 본인 채무 이행을 거절할 수 있도록 규정한 표준하도급계약서와 달리[21] 피심인의 재량권 형태로 대금지급 보류 권한[22]까지 규정하여 수급사업자의 대금 통제권을 실질적으로 제한한다.

35 수급사업자가 보증서 등 별도의 방식으로 하자보수보증금을 제공하였다면 하도급 대금을 온전히 지급받을 수 있었음에도, 본 특약으로 인해 피심인은 대금 자체를 하자보수보증금 명목 등 다른 목적으로 보류·운용할 수 있게 되고, 이는 결과적으로 수급사업자 의사와 무관하게 대금 채권이 보증의무 이행의 담보 등 다른 용도로 강제 전용되는 결과를 초래한다.

36 실제 피심인은 수급사업자 하자보수보증 미이행 시 해당 기성금을 하자보수보증금 명목으로 예치하여 운영하였고, 법 제13조 위반 소지를 이유로 해당 특약을 삭제 조치한 바 있다[23].

37 셋째, 본 특약은 수급사업자의 민법상 동시이행항변권을 배제함으로써, 수급사업자로 하여금 자신의 채무(하자보수보증의무)만을 일방적으로 이행하도록 강제하는 불이익을 초래한다.

---

21) 건설업종 표준하도급계약서는 수급사업자의 하자보수보증 이행과 원사업자의 대금 지급을 상호 대등한 관계의 동시이행적 협조의무로 규정하고 있고, 이로 인해 양 당사자는 상대방 채무의 이행이 있을 때까지 본인 채무의 이행을 거절할 수 있다.

22) 해당 특약은 대금 지급 ‘거절권’과 별도로 ‘보류권’도 규정하고 있는바, ‘거절권’은 상대방이 채무를 이행할 때까지 일시적으로 그 채권의 실현을 저지할 수 있는 ‘항변권’의 성질을 가지는 반면, ‘보류권’은 단순히 대금 지급을 거절하는 것을 넘어 지급해야 할 대금의 집행 자체를 유예하고 그 자금을 내부 통제하에 두는 ‘형성권’ 성격이 강하다. 피심인 주장대로 이 특약이 수급사업자의 의무 이행이 없는 한 대금 지급을 거절할 수 있다는 취지라면, ‘거절권’만으로 충분하나, 그럼에도 별도로 ‘보류권’을 함께 규정한 것은 ‘거절권’과는 다른 목적 즉, 하자보수보증 명목으로 대금을 예치·운용하기 위한 것으로 보는 것이 합리적이다.

23) 소갑 제7호증[기성금 하자보수예치금 보유불가 관련 보고(2021.12.13.)] 참조

38 피심인의 대금지급 보류권으로 인해 수급사업자는 대금을 수령하지 못한 채 본인의 보증의무를 이행한 상태에 놓이게 되는바, 수급사업자는 본인의 동시이행항변권 행사 기회를 상실하게 되고, 양 당사자의 의무 이행 구조가 사실상 수급사업자의 보증 의무가 선행되어야 대금 수령이 가능한 선이행 구조로 전환된다.

39 결과적으로 수급사업자는 피심인으로부터 대금을 받지 못하거나 받기 어려운 상태임에도 본인 채무의 이행을 강제당하고, 자신의 채무 이행을 거절함으로써 피심인의 채무 이행을 촉구할 수 있는 이익[24]이 박탈되는 상황에 놓이게 된다.

40 넷째, 특약 설정의 의도·목적 및 경위를 볼 때, 본 특약은 피심인이 부담해야 할 하자담보 관리 리스크를 기성금 유보라는 방식으로 해결하려는 데에 있는 것으로, 피심인의 편의만을 도모한 특약 설정에 해당한다. 즉, 피심인은 준공 후 발생할 수 있는 하자에 대비하여 담보를 확보할 관리책임이 있음에도, 별도의 행정적 노력 대신 기성금 유보라는 강력한 수단으로 수급사업자를 압박함으로써 자신의 관리책임을 손쉽게 경감할 수 있었다.

41 다섯째, 수급사업자는 해당 특약으로 인해 아무런 보상 없이 자신의 권리만 제한된다는 점에서, 이 특약은 대등한 협의가 아닌 피심인의 우월적 지위를 이용하여 설정된 것으로 볼 수 있다. 특히 본 특약은 피심인이 미리 마련한 약관 조항으로서 수급사업자들은 피심인과의 하도급 거래를 위해 해당 약관 조항에 대한 충분한 검토나 협의 없이 계약이 체결되었을 가능성이 상당해 보인다.

5) 피심인 주장에 대한 판단

가) 이 사건 적용 사례의 하자담보 유보금 해당 여부 관련

42 피심인은 이 사건 적용 사례에 대해, 해당 유보금은 하자담보 유보금이 아닌

24) 동시이행항변권을 행사하는 당사자는 상대방으로부터 대가를 받지 못하거나 받기 어려운 상태에서 자기 채무의 이행을 강제당하지 않고, 상대방이 채무를 이행할 때까지 자기의 채무 이행을 거절함으로써 상대방 채무의 이행을 촉구할 수 있으며, 이를 '동시이행항변권의 담보적 기능'이라고 한다. 하지만 해당 특약으로 인해 피심인만이 이러한 담보적 기능의 혜택을 누리게 된다.

이와 성격이 다른 잔손보기 유보금[25]에 해당하고, 피심인은 실제 하자담보 유보금을 실행한 사실이 없다고 주장한다.[26]

43 그러나 위와 같은 피심인의 주장은 아래와 같은 점에서 인정할 수 없다.

44 첫째, 피심인 소속 이○○ 차장(이하 '이○○ 차장'이라 한다)은 진술조사[27]를 통해 위 사례는 하자담보 유보금이라고 인정한 바 있고, 피심인 주장과 같이 이를 착오로 진술한 것으로 보기는 어렵다.

45 이○○ 차장은 2006년 피심인 본사 공무부[28]에 입사하였고, 현장근무를 거쳐 2018년 12월부터 현재까지 본사 공무부에 근무하고 있는바, 관련 직무 경험, 경력, 직급 등을 고려할 때 진술조사 당시 담당 조사관과의 소통 오류로 잔손보기 유보금을 하자담보 유보금으로 착각하여 진술할 가능성은 낮아 보인다.

46 더욱이, 해당 진술조사는 '잔손보기 기성지급', '하자담보 기성지급', '폐기물 처리비용 공제' 각 항목 순으로 구체적인 자료를 제시하며 진행되었다는 점에서 그 과정상 착오를 일으킬 만한 정황도 보이지 않는다.

47 둘째, 이 사건 실행 사례는 잔손보기 유보금 기준에 부합하지 않는 사정도 존재한다.

48 이○○ 차장의 진술에 따르면, 잔손보기 유보금은 통상 기성금의 3~5%로 설

---

25) '잔손보기'란 건설현장에서 사용되는 용어로, '정해진 일과가 끝난 뒤에 추가적으로 발생한 업무나 작업 마무리(마감)'를 지칭한다. 피심인은 공사 준공 1~2달 전에 잔여공사가 남은 것으로 확인되는 경우, 각 준공 현장별·공종별 특성을 반영하여 수급사업자와 협의하여 총 계약금액의 일정 범위 내에서 하도급대금의 지급을 보류한다. 이후, 수급사업자가 잔여 공사 부분을 마무리하면 피심인은 이에 대한 하도급대금을 지급한다.

26) 본 건 위반은 부당특약 설정행위로, 계약조건의 부당성만을 심사하면 충분하여 위 사례의 하자담보 유보금 해당 여부는 위법성 성립에 직접적 영향을 미치지는 않으나, 위 사례의 하자담보 유보금 해당 여부는 위법성 및 제재 수준 평가에 일정 부분 영향을 미치므로 이에 대해 검토하도록 한다.

27) 소갑 제6호증[피심인 공무부 차장 이○○ 진술조서(2024.4.4.)] 참조

28) 공무부는 협력사 선정, 기성관리 등 '공사 계약 및 외주 관리' 업무, 실행 예산 편성, 원가 분석 등 '원가 및 예산 관리' 업무, 공정표 작성, 진도 관리 등 '공정관리' 업무 등을 담당한다.

정되고, 유보율은 공사 마무리 시점(준공 1~2달 전)에 수급사업자와 협의해서 정한다는 것을 알 수 있다.

49 반면, 이 사건 실행 사례의 경우 계약서상 준공일보다 최소 4~8개월 이전에 설정되었고[29], 유보율 변경 요청 전 기성금 유보율도 10%에 달하였다. 특히, 잔손보기 유보금은 계약서나 특약에 규정되지 않고, 별도 합의서도 존재하지 않는 등 피심인 주장 외 이를 확인할 수 있는 자료 자체가 존재하지 않는다[30].

50 한편, 피심인은 이 사건 실행 사례 중 ○○○○ 및 ○○○○ 사례에 대해 해당 현장은 세부 공종별 공정표에 따라 유보금을 설정하고, 공정표 기재와 같이 해당 시점은 잔손보기 일정에 해당하므로 해당 유보금은 잔손보기 유보금에 해당한다고도 주장하나, 이는 아래와 같은 점에서 받아들일 수 없다.

51 ○○○○ 사례의 경우, 피심인은 ****. *.~****. *. 완료 예정 공정에 대해 ****. *.경 잔손보기 유보금을 설정하였다고 주장하나, ○○○○은 ****. *. **. 기성 유보금으로 인한 재무상 어려움을 이유로 기성유보율을 10%에서 5%로 낮춰줄 것을 요청하였는바, 유보율을 협의·확정한지 불과 10여 일 만에 해당 유보율(10%)로 인해 재무상 어려움이 지속된다며 축소를 요청한다는 것은 상식에 부합하지 않는다.

52 또한, 피심인은 ○○○○ 사례의 경우, ****. *.~****. *. 완료 예정 공정에 대해 그 시작 시점으로부터 이미 2개월이 경과한 ****. *.에 잔손보기 유보금을 설정하였다고 주장하나, 이는 공정 완료 1~2개월 전에 해당 유보금을 설정한다는 기존 진술과도 배치된다. 또한, ○○○○은 ****. *. **. 원가 부담 가중 등을 이유로 기성 유보율을 10%에서 5%로 낮춰줄 것을 요청하였는바, 유보율을 협의·확정한지 불과 10여 일 만에 해당 유보율(10%)로 인해 재무상 어려움이 지속된다며 축소를 요청한다는 것은 위 대성건설 사례와 마찬가지로 경험칙에 부합하지 않는다.

---

29) 유보율 변경 요청 시점이 계약서상 준공일보다 4~8개월 이전이므로 최초 유보율 약정 시점은 그 이전으로 볼 수 있다.

30) 이○○ 차장은 진술조사에서 잔손보기 완료확인서는 모든 현장, 모든 공정에 대해 다 받고 있다고 하였으나, 피심인은 이 사건 실행 사례에 대한 잔손보기 완료확인서를 제시하지 못하고 있다.

나) 건설업종 표준하도급계약서 관련 조항과의 동일성 여부 관련

53 피심인은 이 사건 유보금 특약은 건설업종 표준하도급계약서 제57조 제1항과 사실상 동일하므로 부당 특약에 해당되지 않는다고 주장한다. 하지만 앞서 살펴본 바와 같이, 건설업종 표준하도급계약서 제57조 제1항은 준공검사 완료 이후 수급사업자의 하자보수보증 이행 의무와 원사업자의 대금 지급 의무를 동시이행관계로 규정하고 있는 반면, 이 사건 유보금 특약은 '준공검사 후'라는 명확한 시점 없이 잔여 기성금에 대해서까지 지급 거절을 할 수 있도록 하고 있고, 형성권적 성격의 대금지급 보류 권한까지 부여하여 사실상 수급사업자의 보증 의무 이행이 선행되어야 대금 수령이 가능한 선이행 구조로 전환하고 있다는 점에서 이러한 주장은 받아들일 수 없다.[31)]

6) 소결

54 피심인의 위 2. 가. 1) 행위는 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건을 설정한 행위에 해당하므로 법 제3조의4 제1항 위반에 해당한다.

나. 폐기물 처리비 관련 부당특약 설정행위

1) 인정사실

가) 기초사실(피심인의 폐기물 처리비 지급 과정)

(1) 예상된 폐기물 처리비

55 수급사업자들이 피심인으로부터 위탁받아 건설공사의 세부 공종을 진행하는

31) 다만, '최종기성 일괄 유보 방식'과 같이 준공검사 후 하자담보보증 이행을 확보할 목적으로 대금이 유보되는 경우 실제 자금 흐름은 건설업종 표준하도급계약서 조항이 적용된 경우와 실질적인 차이가 크지 않음은 사실이다.

과정에서, 폐기물은 필연적으로 발생할 수밖에 없다. 예를 들어 타일 시공 업체는 폐타일, 철근 배근 업체는 철근 자투리 등을 발생시킨다.

56 피심인은 완료된 건설현장에서 평균적으로 발생하는 폐기물 처리비용을 기준으로 세부 공종별로 폐기물 처리비용의 수준을 정하여 수급사업자에게 가이드라인을 제시하고, 수급사업자는 해당 가이드라인을 바탕으로 폐기물 처리비용을 포함한 견적서를 제출한다. 이후 이를 계약내역에 반영하여 피심인이 실질적으로 해당 폐기물 처리비용을 납부한다. 이러한 과정을 구체적으로 설명하면 아래와 같다.

57 피심인은 수급사업자에게 제공하는 현장설명서(또는 시방서[32])에 '견적서를 제출할 때 수급사업자의 귀책사유로 발생하는 폐기물 처리비용을 포함하라'고 안내한다.

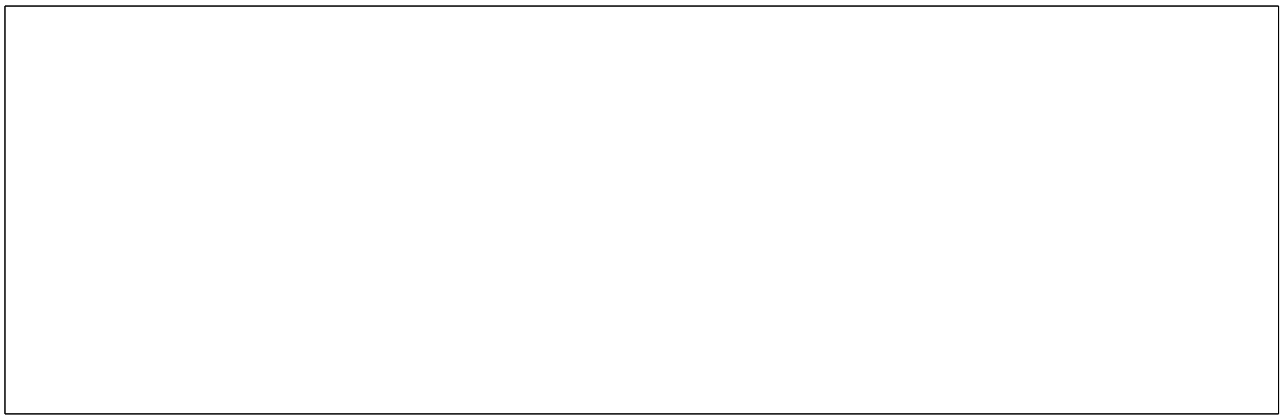
58 수급사업자는 위 안내에 따라 '해당 폐기물 처리비용을 포함한 견적서'를 피심인에게 제출하고, 피심인은 해당 견적서를 바탕으로 수급사업자와 하도급계약을 체결한다. 이 과정에서 해당 폐기물 처리비용은 '간접비 항목 중 폐기물 처리비 금원'으로 반영된다.

59 피심인은 해당 폐기물 처리비용을 폐기물 처리업체에게 직접 지급하는 한편, '해당 폐기물 처리비용'을 피심인이 수급사업자에게 지급해야 하는 기성금에서 공제한다.

60 이 과정에서 피심인은 '해당 폐기물 처리비용을 당사가 수급사업자에게 지급해야하는 하도급대금에서 공제한다'는 내용의 '공제 확인서' 또는 '공제 및 직불 확인서'를 수급사업자로부터 제출받는다. 나아가 수급사업자들로 하여금 동 '공제 확인서' 등에 '추후 어떠한 이의를 제기하거나 소송상, 소송외의 청구를 하지 않을 것을 확약'한다는 문구를 포함시키도록 하였다.

32) '시방서'는 피심인이 수급사업자에게 각 현장에서 제공하는 현장설명서에 포함된 문서로, 수급사업자의 의무, 비용 분담 등에 관한 내용을 포함한다.

<표 14> 피심인의 예상된 폐기물 처리비 지급 공제확인서



* 소갑 제10호증

61 예상된 폐기물 처리비 지급 과정을 예로 들어 설명하면 아래 <표 15>와 같다.

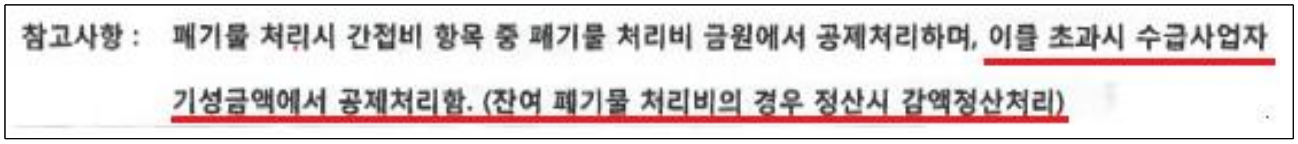
<표 15> 피심인의 예상된 폐기물 처리비 지급 과정 예시

❶ 수급사업자는 폐기물 처리비용 2,000원을 포함한 총 공사대금 10,000원의 견적서를 제출 (해당 2,000원은 '간접비 항목 중 폐기물 처리비 금원'으로 반영)
❷ 피심인은 공사현장에서 발생한 폐기물 처리비용 2,000원을 폐기물 처리업체에게 직접 지급
❸ 피심인은 위 폐기물 처리비용 2,000원을 공제한 8,000원의 공사대금을 수급사업자에게 지급

(2) 예상치 못한 폐기물 처리비

62 공사 진행 과정에서 당초 견적서에 제시된 금액을 초과하여 폐기물 처리비가 발생할 경우, 피심인은 해당 초과분에 대해 수급사업자에게 지급해야 하는 하도급대금에서 공제하였고, 이는 아래 <표 16>과 같이 피심인의 현장설명개요[33]를 통해 확인할 수 있다.

<표 16> 피심인 현장설명개요 중 발췌


참고사항 : 폐기물 처리시 간접비 항목 중 폐기물 처리비 금원에서 공제처리하며, 이를 초과시 수급사업자 기성금액에서 공제처리함. (잔여 폐기물 처리비의 경우 정산시 감액정산처리)

* 소갑 제12호증

33) '현장설명개요'는 각 현장의 공종별 수급사업자 선정을 위한 입찰 진행 시 전체 현장설명서 내용 중 주요사항(현장주소, 현장개요, 입찰일시, 입찰 시 주의사항 등)을 축약하여 기재한 자료이다.

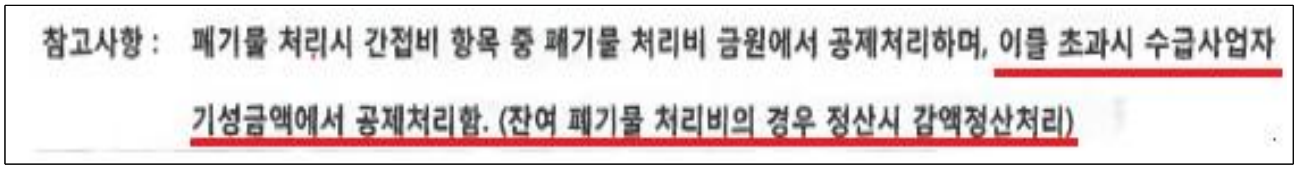
63 피심인은 '계약체결 당시 예상하여 합의된 수준'을 넘어서는 폐기물 처리비용이 발생하는 경우, 그 초과된 폐기물 처리비용은 무조건 수급사업자의 기성금액에서 공제 처리하였다.

64 예를 들어, 위 <표 15>의 예시에서는, 견적서에 포함한 폐기물 처리비용이 2,000원인데, 실제 공사 과정 중 발생한 폐기물 처리비용으로 3,000원이 발생한 경우, 추가 발생한 폐기물 처리비용 1,000원은 수급사업자의 기성금에서 공제한다.

나) 폐기물 처리비 관련 부당특약 설정 경위

65 피심인은 2021. 4. 1.부터 2024. 3. 31.까지[34] 체결 또는 이행된 하도급계약에서, 아래 <표 17>과 같이 당초 예상된 폐기물 처리비 금액을 초과하는 경우 무조건 수급사업자의 귀책사유로 본 후, 기성금액에서 공제하는 내용의 특약을 설정하였다.

<표 17> 현장설명개요 상 특약조항 내용


참고사항 : 폐기물 처리시 간접비 항목 중 폐기물 처리비 금원에서 공제처리하며, 이를 초과시 수급사업자 기성금액에서 공제처리함. (잔여 폐기물 처리비의 경우 정산시 감액정산처리)

* 소갑 제12호증

66 나아가 실제 예상된 폐기물 처리비용을 초과하여 폐기물 처리비가 발생할 경우 피심인은 해당 초과분을 수급사업자들의 기성금에서 공제하면서, 해당 공제 처리에 대해 어떠한 이의를 제기하지 않을 것을 확약하는 확인서를 수급사업자들로부터 제출받기도 하였다.[35]

34) 피심인은 2021. 4. 1. 이전부터 해당 특약을 운용해 왔으나, 법상 조사개시대상 기준 등을 고려하여 2021. 4. 1. 현재 유효하거나 해당일 이후 체결된 하도급 거래로 한정하였다. 한편, 피심인은 2024. 3. 31. 해당 특약의 문제 소지가 있는 문구를 본인의 현장설명개요 등에서 삭제하였다.

35) 이에 따라 실제 **개 수급사업자를 대상으로 한 ***건의 거래에서 총 ***,***,***원(약 *.** 원)이 당초 예상된 폐기물 처리비용을 초과하여 발생하였다. 이는 총 하도급대금 지급금액 ***,***,***,***원(약 *,**** 원)의 *.*%에 해당하는 수치이고, 초과 발생 이유도 천재지변 등 수급사업자의 통제 범위를 벗어난 경우에 해당되지는 않는 것으로 보인다.

<표 18> 피심인의 예상 못한 폐기물처리비 지급 공제확인서

* 소갑 제13호증

67 폐기물 처리비 관련 수급사업자별 하도급계약 현황은 <별지 3>과 같다.

2) 근거

68 위와 같은 사실은 피심인 제출자료(2025.2.14.)(소갑 제1호증), 피심인 제출자료(2024. 12. 10.)(소갑 제2호증), 피심인 제출자료(2024. 1. 24.)(소갑 제3호증), 피심인 제출자료(2025. 2. 28.)(소갑 제4호증), 피심인 공무부 차장 이○○ 진술조서(2024. 4. 4.)(소갑 제6호증), 피심인 제출자료(2024. 12. 30.)(소갑 제9호증), 폐기물 처리비 공제 확인서(소갑 제10호증), 피심인 제출자료(2025. 3. 14.) (소갑 제11호증), 현장설명개요(소갑 제12호증), 초과 폐기물 처리비용 공제 및 직불 확인서(소갑 제13호증), 피심인 제출자료(2025.3.28.)(소갑 제27호증), 피심인 제출자료(2024.5.3.)(소갑 제35호증), 피심인 제출자료(2025.1.6.)(소갑 제36호증), 피심인 제출자료(2025.1.20.)(소갑 제37호증), 피심인 제출자료(2025.3.21.)(소갑 제38호증), 피심인 수급사업자 현황(소갑 제39호증), 폐기물 처리비 관련 내용이 포함된 하도급계약 내역(소갑 제41호증), 심의 과정에서의 전체 진술(PPT 자료 포함) 등을 통해 인정된다.

3) 관련 법령 및 법리

가) 관련 법령

하도급거래 공정화에 관한 법률

제3조의4(부당한 특약의 금지)

① 원사업자는 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건(이하 “부당한 특약”이라 한다)을 설정하여서는 아니 된다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 약정은 부당한 특약으로 본다.

1. 원사업자가 제3조제1항의 서면에 기재되지 아니한 사항을 요구함에 따라 발생된 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정
2. 원사업자가 부담하여야 할 민원처리, 산업재해 등과 관련된 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정
3. 원사업자가 입찰내역에 없는 사항을 요구함에 따라 발생된 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정
4. 그 밖에 이 법에서 보호하는 수급사업자의 이익을 제한하거나 원사업자에게 부과된 의무를 수급사업자에게 전가하는 등 대통령령으로 정하는 약정

하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령[36]

제6조의4(부당한 특약으로 보는 약정) 법 제3조의4제2항제4호에서 "이 법에서 보호하는 수급사업자의 이익을 제한하거나 원사업자에게 부과된 의무를 수급사업자에게 전가하는 등 대통령령으로 정하는 약정"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 약정을 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 비용이나 책임을 수급사업자에게 부담시키는 약정

가. 관련 법령에 따라 원사업자의 의무사항으로 되어 있는 인·허가, 환경관리 또는 품질관리 등과 관련하여 발생하는 비용

(이하 생략)

나) 법리

69 위 2. 가. 3) 나) 기재 내용과 같다.

36) 2024. 5. 7. 대통령령 제34491호로 개정되기 전의 것을 말한다.

4) 위 2. 나. 1) 행위의 위법 여부

70 피심인의 위 2. 나. 1) 행위는 아래와 같은 점에서 관련 법령에 따라 원사업자의 의무사항으로 되어 있는 환경관리와 관련하여 발생하는 비용을 수급사업자에 전가하는 부당한 특약을 설정한 행위에 해당한다.

71 첫째, 건설공사 현장의 폐기물은 관계 법령인 「폐기물처리법[37]」, 「건설폐기물의 재활용 촉직에 관한 법률[38]」 관련 규정에 따라 원사업자인 피심인이 그 처리 의무를 부담한다.

72 둘째, 원인자 부담 원칙에 따라 원사업자인 피심인이 그 의무를 이행하는 데 드는 비용 역시 부담하는 것이 법의 일반 원칙에 부합한다.

73 환경정책기본법은 사업활동으로 환경오염 등의 원인을 제공한 자는 그 오염 등을 방지·회복할 책임을 지며, 그에 따른 비용을 원칙적으로 부담함을 규정[39]하고

37) 「폐기물관리법」
제18조(사업장폐기물의 처리) ① 사업장폐기물배출자는 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자, 제4조나 제5조에 따른 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자, 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제21조에 따라 건설폐기물 처리업의 허가를 받은 자 또는 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」 제19조제1항제1호에 따라 폐기물 해양 배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리하여야 한다.

「폐기물관리법 시행규칙」
제18조(사업장폐기물배출자의 신고) ① 법 제17조제2항에서 “기후에너지환경부령으로 정하는 사업장폐기물배출자”란 지정폐기물 외의 사업장폐기물[생활폐기물로 만든 중간가공 폐기물 외의 중간가공 폐기물, 폐지, 고철(비철금속을 포함한다. 이하 같다), 왕겨 및 쌀겨는 제외한다. 이하 이 조에서 같다]을 배출하는 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
4. 영 제2조제8호의 건설공사 및 영 제2조제9호의 일련의 공사 또는 작업 등으로 인하여 폐기물을 5톤 이상 배출하는 자(공사의 경우에는 발주자로부터 최초로 공사의 전부를 도급받은 자를 포함한다)

38) 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
9. “배출자”란 발주자 또는 발주자로부터 최초로 건설공사 전부를 도급받은 자를 말한다. 다만, 제15조에 따라 건설공사와 건설폐기물 처리용역을 분리 발주한 경우에는 발주자를 말한다.

제16조(건설폐기물 처리용역의 위탁·수탁 계약 등) ① 배출자는 해당 건설공사 현장에서 발생하는 건설폐기물을 스스로 처리하거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 위탁하여 처리하여야 한다. (이하 생략)

39) 「환경정책기본법」
제7조(오염원인자 책임원칙) 자기의 행위 또는 사업활동으로 환경오염 또는 환경훼손의 원인을 발생시킨 자는 그 오염·훼손을 방지하고 오염·훼손된 환경을 회복·복원할 책임을 지며, 환경오염

있는바, 원사업자는 발주자로부터 공사 현장 전체에 대한 관리 권한과 사업 운영권을 부여받아 해당 건설사업을 통해 이윤을 창출하므로 피심인은 위 규정의 '사업활동으로 환경오염 원인을 제공한 자'에 해당한다.

74 또한, 건설기술진흥법령에 따라 환경관리비(환경보전비+폐기물처리비)는 발주자가 원사업자에게 지급하는 확정된 공사비 항목이므로[40], 폐기물처리비는 원사업자의 사업 수행에 따라 수반되는 당연한 비용이라고 할 수 있다.[41]

75 셋째, 본 특약은 초과비용 발생에 대한 귀책 여부를 불문하고 수급사업자에게 전적으로 그 비용을 전가하고 있는바, 초과 폐기물 발생 원인이 수급사업자의 통제 범위를 벗어난 경우[42]에도 단순히 산술적 평균(평균 폐기물 처리비)을 넘었다는 이유만으로 수급사업자의 귀책으로 돌리는 것은 그 자체로 상당성을 결여한 것이다.[43]

5) 피심인 주장에 대한 판단

76 피심인은 '(계약예규) 공사계약일반조건' 제23조의3 규정[44]과 평균 폐기물 처

또는 환경훼손으로 인한 피해의 구제에 드는 비용을 부담함을 원칙으로 한다.

40) 「건설기술진흥법」
제66조(건설공사의 환경관리)
③ 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용(이하 "환경관리비"라 한다)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

「건설기술진흥법 시행규칙」
제61조(환경관리비의 산출 등) ① 법 제66조제3항에 따른 건설공사의 환경관리에 필요한 비용(이하 "환경관리비"라 한다)은 다음 각 호의 비용을 합하여 산정한다.
1. 건설공사현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용
2. 건설공사현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용
② 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 제1항에 따른 비용의 사용계획을 같은 항 제1호에 따른 환경오염 방지시설을 최초로 설치하기 전까지 발주자에게 제출하고, 발주자 또는 건설사업관리용역사업자가 확인한 비용 중 간접공사비에 대해서는 그 사용실적에 따라 정산해야 한다.

41) 부당특약 관련 시행령 및 심사지침도 환경정책기본법, 건술기술진흥법령 등 관련 법령의 취지를 반영하여 환경관리 의무와 그 수반 비용을 원사업자가 부담해야 한다는 원칙을 기본 전제로 규정하고 있다.

42) 천재지변, 원사업자가 제공한 자재의 불량, 선행 공정의 미비, 현장 여건의 변화 등

43) 더불어, 피심인은 초과 폐기물 발생과 관련된 수급사업자의 이의제기도 원천적으로 차단함으로써, 본 특약을 달리 해석하거나 수급사업자의 책임 범위를 제한적으로 볼 수 있는 여지마저 봉쇄하였다.

44) 「(계약예규) 공사계약일반조건」
제23조의3(건설폐기물량의 초과발생에 따른 계약금액의 조정) 시행령 제78조에 따라 체결된 계약에 있어서 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제15조에 따라 건설공사와 건설폐기물처리용역을

리비를 계약 내역에 포함하여 본인이 부담하고 있는 점을 근거로 초과 폐기물 처리비는 수급사업자가 전적으로 부담하는 것이 타당하다고 주장하나, 이는 아래와 같은 점에서 받아들일 수 없다.

77 첫째, '(계약예규) 공사계약일반조건'은 국가(발주기관)와 원사업자(계약상대방) 사이의 관계를 규정한 것으로 이를 곧바로 원사업자와 수급사업자 간의 하도급 관계에 일률적으로 적용할 수는 없다.

78 둘째, '(계약예규) 공사계약일반조건' 제23조의3 규정의 핵심 요건은 '계약상대자가 설계시 산출한 물량을 초과하여 발생한 때'로, 계약상대자에게 설계 권한이 있음을 이유로 그 설계 책임을 부담시키는 것에 있다. 반면, 본 건의 경우 수급사업자는 피심인의 가이드라인에 따라 폐기물 처리비 견적을 제시할 수밖에 없으므로 위 규정에 따르더라도 수급사업자의 귀책이 없는 부분까지 그 비용을 부담시키는 특약은 부당하다.

79 셋째, 피심인은 평균 폐기물 처리비를 계약 내역에 반영하였다는 점을 근거로 내세우고 있으나, 피심인 스스로도 세부 공종별 폐기물 발생 수준을 정밀하게 구분하는 것이 불가능함을 인정하고 있는바, 이처럼 현장의 실질적 발생 요인을 반영하지 못한 채 산정된 '평균 폐기물 처리비'는 객관적인 관리 기준이 될 수 없다. 따라서 이러한 불명확한 기준을 근거로 발생 물량이 평균치를 초과하였다는 사실만 가지고 이를 곧바로 수급사업자의 귀책으로 단정하여 비용을 전가하는 것은 논리적으로 타당하지 못하다.

80 더욱이, 위에서 살펴본 바와 같이, 수급사업자는 폐기물 처리비 견적 산출 시 피심인이 제시한 가이드라인을 준수해야 하므로, 실제 발생할 것으로 예상되는 비용보다 피심인의 예산 범위에 맞춰 견적을 작성할 수밖에 없다. 이러한 사정을 고려할 때, 당초 계약에 반영된 평균 폐기물 처리비 자체도 객관적이고 실질적인 공사 여건

분리발주한 경우로서 공사수행과정에서 건설폐기물이 계약상대자가 설계시 산출한 물량을 초과하여 발생한 때에는 해당 초과물량에 대하여 발주기관이 실제 폐기물처리업체에 지급한 처리비용만큼 계약금액에서 감액조정한다.

을 반영한 합리적인 금액이라고 인정하기 어렵다.

81 넷째, 계약 내역에 편성된 비용은 공사 수행을 위한 확정적 성격의 기본 공사비인 반면, 이를 초과하여 발생하는 비용은 현장의 불확실성에 따른 예측 불가능한 리스크에 해당한다. 따라서 원사업자인 피심인은 이러한 리스크를 관리하고 적정 예산을 편성할 책임이 있음에도, 본 특약을 통해 그 발생 원인이나 귀책 사유에 대한 구체적인 검토 없이 초과 비용 전액을 수급사업자에게 전가하고 있다는 점에서도 본 특약의 타당성을 인정하기 어렵다.

6) 소결

82 피심인의 위 2. 나. 1) 행위는, 관련 법령에 따라 원사업자의 의무사항으로 되어 있는 환경관리와 관련하여 발생하는 비용을 수급사업자에 전가하는 부당한 특약을 설정한 행위에 해당하므로 법 제3조의4 제1항 및 제2항 위반에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치

83 피심인의 위 2. 가. 1) 및 2. 나. 1) 행위는, 향후 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로, 법 제25조에 따라 피심인에게 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

1) 과징금 부과 여부

84 피심인의 위 2. 가. 1) 행위는 다수 수급사업자에 대한 하도급대금 지급 조건과 관련된 사안으로 공정한 하도급거래질서 확립에 미치는 파급효과가 상당하다고 인정되므로 법 제25조의3 제1항, 같은 법 시행령 제13조 [별표 2] 및 「하도급법 위

반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시」[45]의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

2) 기본산정기준

85 피심인의 위 2. 가. 1) 행위는 위반금액이 정의되지 않는 행위유형으로 위반금액의 비율을 산정하기 곤란한 경우에 해당하므로 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. 규정에 따라 10억 원 이내에서 중대성의 정도를 고려하여 기본산정기준을 도출한다.

86 피심인의 위 2. 가. 1) 행위는, 피심인이 이 사건 유보금 특약을 자체 점검하여 시정한 점, 본 특약으로 인해 하도급대금이 실제 지연 지급된 사례는 명확히 확인되지 않는 점 등을 고려할 때 '중대성이 약한 위반행위'에 해당하므로 100,000,000원을 기본산정기준으로 정한다.

3) 1차 및 2차 조정 산정기준

87 피심인의 위 2. 가. 1) 행위는, 과징금 고시 Ⅳ. 2. 규정에 따른 1차 조정 사유는 없으며, 과징금 고시 Ⅳ. 3. 나. (2) (나) 규정[46]에 따라 심의대상이 된 법 위반행위가 2년 이상[47]의 기간에 걸쳐 반복적으로 발생하거나 지속된 경우에 해당하므로 기본산정기준의 100분의 45에 해당하는 금액을 가산하고, 이에 따른 2차 조정 산정

45) 2022. 12. 30. 공정거래위원회고시 제2022-27호로 개정되기 전의 것을 말하고, 이하 '과징금 고시'라 한다.

46) 과징금 고시
Ⅳ. 과징금의 산정
3. 2차 조정
나. 가중사유 및 비율은 다음과 같이 정한다.
(2) 위반행위의 동질성이 인정되어 동시에 심의대상이 된 법 위반행위가 1년 이상의 기간에 걸쳐 반복적으로 발생하거나 지속된 경우로서 Ⅳ.1.다.의 규정에 따라 과징금을 부과하는 경우
(가) 기간이 1년 이상 2년 미만인 경우 : 100분의 10 이상 100분의 20 미만
(나) 기간이 2년 이상인 경우 : 100분의 20 이상 100분의 50 미만
단, 위 기간을 산정함에 있어 행위의 실행이 종료되었더라도 사업자가 그 실행의 결과를 유지하면서 그로 인하여 지속적으로 이익을 취득하거나 손해를 발생시키고 있는 경우에는 이익의 취득 혹은 손해의 발생이 종료된 날까지 행위가 지속된 것으로 본다.

47) 해당 위반행위는 이 사건 하자담보 유보금 특약이 설정된 계약 중 '최초 계약 시작일'인 2016. 4. 11. 부터 해당 특약이 설정된 계약 중 '최종 계약 종료일'인 2024. 3. 31.까지 약 8년에 걸쳐 반복적으로 발생하거나 지속되었다.

기준은 145,000,000원이다.

4) 부과과징금 결정

88 피심인에게 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. 규정에 따른 조정 사유는 없으므로 2차 조정 산정기준 145,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

89 피심인의 위 2. 가. 1) 행위는 법 제3조의4 제1항, 위 2. 나. 1) 행위는 법 제3조의4 제1항 및 제2항에 각각 위반되므로, 시정조치에 대해서는 법 제25조, 과징금 부과에 대해서는 법 제25조의3 제1항을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2026년 5월 4일

의 장 위 원 황 원 철

위 원 신 영 수

위 원 최 한 수

[별지 1]

피심인의 수급사업자 일반현황

(단위 : 백만 원, 부가가치세 포함)

순번	수급사업자명	매출액			시공능력평가액		
		2021년	2022년	2023년	2021년	2022년	2023년
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							

43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							

93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							

143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							

193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							
203							
204							
205							

* 소갑 제39호증

** 폐업 등으로 일부 업체 현황 파악 불가

[별지 2]

2021.4.1.부터 2022. 3. 14. 내 체결 또는 이행된 하도급 계약 현황

(단위 : 천 원, 부가가치세 포함)

순번	수급사업자명	하도급 계약명	계약 시작일	계약 종료일	하도급대금 지급금액
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					

68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					

103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					

138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					

172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					

207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					

241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					

275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					
294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					

309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					

344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					
368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					

379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					
401					
402					
403					
404					
405					
406					
407					
408					
409					
410					
411					
412					
413					

414					
415					
416					
417					
418					
419					
420					
421					
422					
423					
424					
425					
426					
427					
428					
429					
430					
431					
432					
433					
434					
435					
436					
437					
438					
439					
440					
441					
442					
443					
444					
445					
446					
447					
448					
449					

450					
451					
452					
453					
454					
455					
456					
457					
458					
459					
460					
461					
462					
463					
464					
465					
466					
467					
468					
469					
470					
471					
472					
473					
474					
475					
476					
477					
478					
479					
480					
481					
482					
합계					

* 소갑 제40호증 참고

[별지 3]

폐기물 처리비 관련 내용이 포함된 하도급계약 내역

(단위 : 개, 천 원, 부가가치세 포함)

순번	수급사업자명	예상된 폐기물 처리비			초과 폐기물 처리비		
		계약 건수	예상 비용	하도급 대금 지급 금액	계약 건수	초과 비용	하도급 대금 지급 금액
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							

44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							

94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							

144							
145							
146							
합계							

* 소갑 제41호증